

<별첨> 경쟁제한성 판단기준

1. 일반원칙

이 지침에서 III. 1. 가. (2) (다)에서 정의한 경쟁제한성은 구체적으로는 당해 행위로 인하여 시장 가격 상승 또는 시장 전체의 생산량 축소가 발생하거나 발생할 가능성을 의미한다.

경쟁제한효과는 경쟁사업자 간 담합(collusion) 또는 시장력(market power)이 있는 사업자가 경쟁사업자를 배제(exclusion)하는 것에서 비롯되는 바, 경쟁제한요건 행위는 사업자간 합의가 아닌 단독행위의 성격을 가지므로 동 행위의 경쟁제한성은 경쟁사업자 배제효과에서 비롯된다. 따라서, 경쟁제한요건 행위의 경쟁제한성은 경쟁사업자 배제효과를 분석하여 판단한다.

다만, 경쟁사업자 배제효과가 있다고 하더라도 모두 경쟁제한효과가 있는 것은 아니다. 다수 사업자가 경쟁하는 시장에서 특정사업자가 배제된 것에 불과하여 시장경쟁의 성과에 변화가 초래되지 않는 경우라면 경쟁제한효과는 없다. 단순히 경쟁사업자가 배제되었다는 이유만으로 경쟁제한성이 없는 행위를 규제하는 것은 시장의 경쟁을 보호하는 것이 아니라 경쟁사업자를 보호하는 과도한 시장개입이 될 우려가 크다

시장력(market power)이 있는 사업자에 의해 경쟁사업자를 배제하는 경쟁제한요건 행위가 행해지는 경우 경쟁제한효과를 수반할 가능성이 높다. 여기서, 시장력(market power)이란 사업자가 시장의 가격이나 거래조건 등 시장경쟁의 성과에 어느정도 영향을 미칠 수 있는 힘을 의미한다.

이와 같이, 시장력(market power)이 있는 사업자에 의해 경쟁제한요건 행위가 행해져야 경쟁제한효과가 발생하므로 행위주체가 시장력(market power)을 보유하고 있는지를 판단하여야 한다. 이를 위해서는 우선 적절한 관련 시장을 확정하여야 하고, 확정된 관련시장에서 시장력(market power)이 있는지 여부를 판단하여야 한다.

한편, 경쟁제한효과를 수반하는 경쟁제한요건 행위가 효율성을 제고하는 경우도 있으므로 경쟁제한효과가 있다고 하더라도 그 자체만으로 위법성을 인정할 것이 아니라 당해 행위가 가질 수 있는 효율성 증대효과와 비교형량하여야 한다. 법 제23조에 규정된 부당성 요건은 경쟁제한요건 행위의 경우 경쟁제한효과가 효율성 증대효과 보다 큰 경우에 충족된다.

2. 경쟁제한성 판단기준

경쟁제한요건 행위의 위법성은 ①시장력(market power)을 보유한 사업자가 ②경쟁제한효과가 있는 경쟁제한요건 행위를 행하고 ③동 경쟁제한효과가 효율성 증대효과 보다 큰 경우에 인정된다.

가. 행위주체의 시장력(market power) 보유

행위주체의 시장력(market power)을 판단하기 위해서는 기본적으로 문제된 행위와 관련된 시장이 적정하게 확정되어야 한다.(관련시장 확정은 기업결합 심사기준의 일정한 거래분야 판단기준을 준용한다.)

원칙적으로 행위주체가 확정된 시장에서의 시장점유율이 30% 이상인 경우에는 행위주체의 시장력(market power)이 인정되나, 시장점유율이 20%에서 30% 사이인 경우도 시장집중도, 경쟁상황, 상품의 특성 등 제반사정을 고려하여 시장력(market power)이 인정될 수 있다. .

시장점유율이 10% 이상인 경우에는 다수의 시장참여자들이 동일한 행위를 하고 그 효과가 누적적으로 발생하거나 발생할 우려가 있는 경우(누적적 봉쇄효과)에 한하여 시장력(market power)이 인정될 수 있다. .

나. 경쟁제한요건 행위 및 경쟁제한효과의 입증

경쟁제한요건 행위가 자기 또는 계열사의 경쟁사업자를 배제하는 행위인지를 판단하고, 그 행위로 인하여 시장 경쟁이 제한되는 지를 입증하여야 한다. 직접적으로 자기 또는 계열사의 경쟁사업자를 대상으로 하는 행위가 아니더라도 자기 또는 계열사의 경쟁사업자를 배제하는 효과를 수반한다면 경쟁제한요건 행위가 행해진 것으로 본다.

시장력(market power)을 보유하고 있는 사업자에 의해 경쟁제한요건 행위가 행해진 경우에는 경쟁제한 효과가 나타날 가능성이 크다.

다. 효율성 증대효과와의 비교형량

경쟁제한효과가 인정되더라도 동 행위의 효율성 증대효과에 대한 주장이 제기되는 경우에는 이를 비교형량하여야 한다. 경쟁제한효과 보다 효율성 증대 효과가 더 크다는 것을 입증하기 위해서는 ①기술적 진보나 생산·유통비용의 절감과 같은 효율성의 존재, ②이러한 효율성을 달성하기 위한 보다 덜 경쟁제한적인 방법이 없다는 사실, ③효율성 증대에 따른 이익이 경쟁제한에 따른 피해보다 크다는 사실 등을 입증하여야 한다.

3. 개별행위 유형별 경쟁제한성 판단기준

가. 목적 및 적용범위

경쟁제한요건 행위 중 단독의 거래거절, 차별취급, 부당염매 행위에 적용된다. 단독의 거래거절이란 이 지침에서 기타의 거래거절로 규정된 행위를 의미한다.

단독의 거래거절, 차별취급 및 염매 행위는 원칙적으로 시장경제에서 개별사업자가 자유롭게 할 수 있는 행위이므로 기본적으로 사회적 비난가능성이 적은 행위이다. 이러한 점을 고려하여 독점력(monopoly power 또는 market dominant power)을 보유한 사업자가 행하는 경우에만 규제하고 있는 것이 주요국가의 법집행기준이다.

여기서 독점력(monopoly power 또는 market dominant power)이란 시장경쟁의 성과에 실질적인 영향을 미칠 수 있는 힘을 의미한다. 주요 국가 경우 독점력(monopoly power 또는 market dominant power)은 원칙적으로 50% 이상의 시장점유율을 보유한 제1위 사업자에 한하여 인정된다.

불공정거래행위로서 상기 행위를 규제하고 있는 것은 시장이 독과점화 되기 전에 보다 선제적으로 경쟁제한적 피해를 방지하기 위한 것이나 주요국가의 법집행 기준을 고려하는 것이 바람직하므로 보다 합리적인 심사기준을 통해 법 집행의 정합성을 제고할 필요가 있다.

나. 단독의 거래거절

모든 사업자는 거래상대방을 선택할 자유가 있다. 이를 과도하게 제약할 경우 시장효율에 부합하는 기업판단을 억제하고 소비자 이익을 저해할 수 있으므로 이에 대한 규제는 매우 신중하여야 한다.

따라서, 단독의 거래거절은 행위주체가 원칙적으로 시장점유율이 30% 이상으로 시장력 (market power)이 인정되는 경우에만 규제하는 것이 바람직하다. 이러한 시장력 (market power)을 다수의 사업자가 보유할 가능성은 적으므로 누적적 봉쇄효과를 이유로 규제할 필요성도 미미하다. 다수의 사업자에 의한 거래거절은 공동의 거래거절로 규제하는 것이 주요 국가의 법집행 관행이다.

단독의 거래거절은 통상 자기 또는 계열사가 경쟁하는 시장에서 경쟁사업자를 배제하여 시장의 경쟁을 제한하는 경우가 규제 대상이 되며, 경쟁사업자가 아닌 단순히 고객 등에 대한 단독의 거래거절은 위법성이 인정되기 어렵다. 다만, 경쟁자 배제를 위한 것일 경우에는 예외적으로 위법성이 인정될 수도 있다.

상당한 정도의 시장력 (market power)을 보유한 사업자가 하위시장에도 참여하여 경쟁하고 있는 상황에서 하위시장의 경쟁사업자에게 그가 필요로 하는 자신의 상품 공급을 거절하는 경우에는 위법성이 인정될 가능성이 크다. 이와 달리 하위시장에 참여하고 있지 않은 경우에는 통상 경쟁사업자 배제효과가 수반되지 않으므로 위법성이 인정되기 어렵다.

거래거절은 시장경제하에서 원칙적으로 자유로이 행해질 수 있는 것이므로 이를 규제하기 위해서는 엄격한 기준이 필요하다. 예를 들어 대상 상품이 경쟁사업자의 사업활동에 필수적인 제품인지 여부, 거래거절에 정당한 사유가 있는지 여부에 대한 고려가 필요하다.

다. 차별취급

사업자는 가격, 거래조건 등을 거래지역이나 거래상대방에 따라 달리 정할 수 있는 것이고, 이에 대한 규제는 가격인하나 혁신을 처벌하는 결과가 될 수 있으므로 단독의 거래거절과 마찬가지로 매우 신중하여야 한다.

차별취급은 자기 또는 계열사의 경쟁사업자를 차별하여 경쟁사업자가 배제되고 이로 인하여 시장의 가격 상승 등 경쟁제한효과가 발생하는 경우에 규제하는 것이므로 원칙적으로 행위주체가 시장점유율이 30% 이상으로 시장력 (market power)이 인정되는 경우에만 규제하는 것이 바람직하다.

차별취급은 주로 1선 시장(차별취급을 행하는 판매자의 상품이 속한 시장)에서 문제가 되나, 예외적으로 1선 시장에서 시장력 (market power)을 보유한 사업자가 2선 시장

(구매자 또는 그 구매자의 구매자가 속한 시장)에서 서로 경쟁하는 사업자를 차별하고 이로 인해 가격 상승 등 경쟁제한효과가 발생하는 경우에도 문제될 수 있다. 다만, 2선 시장에서 차별취급으로 인하여 경쟁제한효과가 발생하기 위해서는 2선 시장의 시장집중도가 높을 것이 요구된다. 그리고 이를 입증하기 위해서는 관련시장 획정이 필요하다.

차별취급은 일반적으로 거래물량, 운송거리, 거래조건 등에 따라 합리성이 인정될 수 있으므로 이에 대한 고려가 필요하다. 2선 차별의 경우 일반적으로 그 목적이 경쟁사업자를 배제하는 것이 아닌 경우에는 합리적인 이유가 있는 경우가 대부분이다.

라. 부당염매

자유시장경제에서 가격은 대표적인 경쟁수단으로서 가격인하를 통해 경쟁자의 고객을 확보하는 행위는 자연스러운 경쟁과정이다. 가격인하를 규제할 경우 비효율적인 경쟁자를 보호하거나 기업의 예측 가능성을 저해하여 가격인하 경쟁 자체를 위축시킬 우려가 있으므로 규제는 매우 신중하여야 한다.

시장이 상당히 독과점화 되어 있지 않는 경우에는 부당염매로 인하여 자기 또는 계열사의 경쟁사업자가 배제되고 이로 인하여 시장의 가격이 상승하는 등 경쟁제한효과가 발생하기 어렵다. 따라서, 부당염매를 규제하기 위해서는 원칙적으로 행위주체가 시장점유율이 30% 이상으로 시장력(market power)이 인정되는 경우에만 규제하는 것이 바람직하다.

부당염매는 비용 보다 낮게 설정된 가격으로 판매하는 것을 의미하므로 타 사업자에 비하여 낮은 가격으로 판매하는 것 자체는 문제가 아니며 가격이 적절히 산정된 비용 이하인지 여부, 그리고 이러한 낮은 가격이 배제효과를 수반할 정도로 의미 있는 기간동안 지속되었는지 여부가 중요한 위법성 판단기준이다.